

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 `법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때`에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 `이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때`에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 상고심이 원칙적으로 상고이유서에 기재된 범위 내에서만 심리하는 법률심임에도 불구하고, 丙의 사례와 같이 상고이유에 포함되지 않은 소송 요건이나 전속관할 위반 등의 사항을 대법원이 직권으로 조사하여 판단할 수 있는지 그 근거와 한계에 대하여 기술하시오.》

<문제15.2의 물음2> 상고심의 직권조사사항의 근거와 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하면서 이유불비 등의 상고이유를 주장하였으나, 상고심 법원이 소송요건이나 전속관할 위반 여부를 별도로 발견한 상황이다. 쟁점으로 <법률심인 상고심이 상고이유서에 기재되지 않은 사항에 대하여도 직권으로 조사·판단할 수 있는지와 그 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고심의 심리범위와 직권조사사항의 인정 근거 및 한계를 기술한다.

II. 상고심의 심리 범위와 직권조사사항

1. 변론주의와 직권조사사항의 관계

(1) 원칙(상고이유 구속의 원칙)

- "민사소송법 제431조"에 의하면 상고법원은 상고이유에 의하여 불복신청한 범위 안에서 심리한다. 이는 당사자가 제기한 오류에 대해서만 판단하겠다는 취지이다.

(2) 예외(직권조사사항)

- 소송요건이나 전속관할, 소송대리권의 존부 등 소송의 전제가 되는 사항은 당사자의 주장 여부와 상관없이 법원이 스스로 조사하여 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 공공의 이익과 직결되는 절차적 정당성을 확보하기 위함이다.

2. 민사소송법상 근거

(1) 제434조(준용규정)

- 상고심 절차에는 항소심의 규정이 준용되며, 항소심에서는 소송요건 등 직권조사사항에 대해 당사자의 불복 유무를 불문하고 심리할 수 있다.

(2) 제429조 단서

- 상고이유서 제출기한을 초과하더라도 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 상고를 기각할 수 없다고 규정하여, 직권조사사항이 상고이유에 우선함을 명시하고 있다.

III. 직권조사사항의 구체적 범위와 근거

1. 소송요건 및 소송대리권

- 소송요건은 법원이 소송의 주체, 객체, 절차에 관하여 공익적 견지에서 미리 확정해 두어야 할 사항이다. 특히 소송대리권의 흠결은 적법한 절차를 거치지 않은 재판이 될 우려가 있으므로 상고심에서도 반드시 직권으로 조사해야 한다.

2. 전속관할

- 관할권 중 전속관할은 국가의 사법행정상 이유나 공익적 목적에 의해 강제된 것이므로, 당사자의 합의나 변론으로 변경할 수 없다. 따라서 전속관할 위반 여부는 상고심의 직권조사 대상이 된다.

3. 절대적 상고이유

- "민사소송법 제424조 제1항 각 호"에 규정된 절대적 상고이유(법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사의 관여 등)는 그 하자가 매우 중대하여 당사자의 주장이 없더라도 대법원이 스스로 파악하여 파기 사유로 삼을 수 있다.

IV. 직권조사의 한계

1. 사실인정의 한계

- 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없는 것이 원칙이다. 따라서 직권조사사항이라 하더라도 그 기초가 되는 사실관계가 원심 판결문이나 기록에 나타나 있어야 한다. 다만, 소송요건 중 법원의 권한에 속하는 사항은 필요한 경우 예외적으로 사실을 탐지할 수 있다.

2. 상고의 이익에 의한 한계

- 상고인은 자기에게 불이익한 판결에 대해서만 상고할 수 있다. 직권조사사항이라 하더라도 원심 판결이 상고인에게 유리하게 선고되었다면, 상고인이 주장하지 않은 유리한 직권조사사항을 근거로 원심을 파기하는 것은 상고의 이익 원칙에 반할 수 있다.

3. 처분권주의와의 관계

- 청구의 당부와 직접 관련된 본안의 사실관계는 직권조사의 대상이 될 수 없다. 소멸시효의 완성이나 채무의 변제와 같은 항변 사항은 당사자가 상고이유로 주장하지 않는 한 대법원이 직권으로 판단할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丙의 상고이유와 직권조사사항의 관계

- 사안에서 丙은 이유불비 및 이유모순을 상고이유로 들었으나, 대법원이 인지한 소송대리권의 흠결 및 전속관할 위반은 소송요건 및 공익적 관할에 관한 사항이다. 이는 민사소송법상 직권조사사항에 해당하므로 丙의 상고이유 포함 여부와 관계없이 대법원이 심리할 수 있다.

2. 대법원의 판단 가능성

- 대법원은 상고이유서에 기재되지 않은 사항이라 하더라도 소송대리권 흠결 여부를 조사하여야 한다. 만약 대리권이 없거나 전속관할을 위반한 사실이 기록상 확인된다면, 丙이 주장한 이유불비에 대한 판단에 앞서 원심판결을 직권으로 파기하고 사건을 환송하거나 이송하여야 한다.

Ⅴ. 결론

- 상고심은 법률심으로서 상고이유에 구속되는 것이 원칙이나, 소송요건이나 전속관할 위반 등과 같은 직권조사사항에 대해서는 그 한계를 준수하는 범위 내에서 상고이유에 포함되지 않았더라도 직권으로 심리·판단할 수 있다. 이는 사법 정의의 실현과 적법절차의 원칙을 수호하기 위한 법원의 책무이기 때문이다. 따라서 대법원은 丙의 사례에서 발견된 절차적 흠결을 직권으로 조사하여 판결에 반영할 수 있다.